INTRODUÇÃO
AO DIREITO CIVIL

Docente: Fabiana Dantas Soares Alves da Mota

Monitoras: Maíra Fernanda França e Laura Dias

NOÇÕES CONCEITUAIS

Precedentes e codificação:

Ordenações do Reino ou Afonsinas (1446);

Ordenações Manuelinas (1521);

Ordenações Filipinas (1603);

A Constituição do Império previu o Código Civil baseado na Justiça e Equidade (1824);

Teixeira de Freitas (1865) – Esboço do Código Civil (rejeitado) – Influência no Direito Argentino;

Após a Proclamação da República, Clóvis Beviláqua foi designado para a função, chegando em 1900 o Projeto do Código Civil ao Congresso Nacional, aprovado em 1916, entrando em vigor em 1º de Janeiro de 1917;

O CC 1916 foi revogado pelo CC 2002, no dia 11 de janeiro de 2003, supervisionado por Miguel Reale e fundado em valores éticos e sociais.

NOÇÕES CONCEITUAIS

- **DIREITO: O Direito existe para pacificar e disciplinar a vida em sociedade e, por outro lado, tem de espelhar as necessidades dessa sociedade. É a normatização da conduta humana, com vistas à garantia da vida em sociedade.**
  - **Para Francisco Amaral: "O Direito surge ao longo de um processo histórico, dialético e cultural, como uma técnica, um procedimento de solução de conflito de interesses e, simultaneamente, como um conjunto sistematizado de normas de aplicação mais ou menos continua aos problemas da vida social, fundamentado e legitimado por determinados valores sociais".**

NOÇÕES CONCEITUAIS

- **Direito objetivo x Direito subjetivo**

Enquanto a expressão direito objetivo exprime o conjunto das regras normativas que disciplinam um determinado ordenamento, o direito subjetivo, por seu turno, diz respeito ao poder de exigir ou de pretender de alguém um comportamento específico.

- **Ex.: Direito das Sucessões x Direito de suceder.**

DIREITOS SUBJETIVOS X DIREITOS POTESTATIVOS

DIREITOS SUBJETIVOS:

- **Pretensão conferida ao titular, paralelamente a um dever jurídico imposto a outrem;**
- **Admite violação;**
- **É coercível;**
- **Depende da vontade do titular.**

DIREITOS POTESTATIVOS:

Atribuem ao titular a possibilidade de produzir efeitos jurídicos em determinadas situações mediante um ato próprio de vontade, inclusive atingindo terceiros interessados nessa situação que não poderão se opor.

- **O exercício dos direitos potestativos dispensa comportamento do sujeito passivo. Os direitos potestativos são poderes do titular de formar situações jurídicas pela sua própria vontade, impondo a terceiros determinados comportamentos.**

DIREITOS SUBJETIVOS X DIREITOS POTESTATIVOS

Os direitos potestativos conferem ao titular o poder de produzir consequências na esfera jurídica de outro sujeito em decorrência de sua exclusiva manifestação de vontade. Por isso, ao revés do direito subjetivo, o direito potestativo não admite violação.

(CC, art. 1.804)

NOÇÕES CONCEITUAIS

- **Direito positivo x Direito consuetudinário (costumeiro)**

  Direito positivo = norma escrita, positivada.

  Direito consuetudinário = resultante dos usos e costumes, common law inglês.
- **O positivismo jurídico – um cumprimento estrito da lei escrita, por mais absurda que se mostrasse.**
- **Dura lex sed lex = "a lei é dura, mas é a lei".**
- **Pós-positivismo – Direito como agente de transformação e de participação na sociedade, abandonando-se a neutralidade e indiferença.**
- **Direito natural – o reconhecimento da existência de um direito, de uma justiça, anterior e acima do direito positivo vigente.**
- **Crítica diz respeito justamente no ponto que devemos considerar o Direito como uma construção humana, cultural.**

DIREITO PÚBLICO X DIREITO PRIVADO

- Direito público = interesse geral.
- Direito privado = interesse individualizado, do titular.
- Superação da dicotomia direito público e privado.
- CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO CIVIL.
  - Previsão constitucional de institutos nitidamente civilistas (Ex.: família, propriedade e contrato).
- Novo vértice axiológico constitucional:
  - A dignidade da pessoa humana (art. 1º, III);
  - A solidariedade social (art. 3º);
  - A igualdade substancial (arts. 3º e 5º);
  - A erradicação da pobreza e redução das desigualdades sociais, promovendo o bem de todos (art. 3º, III e IV).
- Interpenetração entre direito público e direito privado.

FONTES DO DIREITO

- **“A expressão fontes do direito é utilizada de forma figurada para designar o ponto de partida para o surgimento do direito e do seu estudo, a ciência jurídica.” (TARTUCE, 2017, p. 16)**

Fontes do Direito

Formais, diretas ou imediatas

*Lei

*Analogia

*Costumes

*Princípios gerais do Direito

Conforme o Art. 4º da LINDB

Não formais, indiretas ou mediatas

*Doutrina

*Jurisprudência

LACUNAS DO DIREITO

A Lei é a principal fonte do Direito, porém o sistema jurídico não é perfeito. Isto é, há lacunas no ordenamento, as quais a legislação, por si só, não é capaz de suprir – “Entretanto, de acordo com as suas lições, as lacunas não são do direito, mas da lei, omissa em alguns casos.” (Flávio Tartuce, 2018).

Segundo Maria Helena Diniz, há quatro tipo de lacunas: lacunas normativas, ontológicas, axiológicas e lacuna de conflito ou antinomia.

Mas o juiz não pode se eximir de seu dever de julgar e por isso, ele recorre a processo de integração da norma jurídica, que consiste no uso de alguns mecanismos de preenchimento das lacunas. Que são: analogia, costumes e princípios gerais do Direito.

INTEGRAÇÃO DA NORMA JURÍDICA

- **Analogia: “É a aplicação de uma norma próxima ou de um conjunto de normas próximas, não havendo uma norma prevista para um determinado caso concreto.” (Tartuce, 2019)**
- **Analogia legal**
- **Analogia jurídica**
- **Costumes: “Os costumes podem ser conceituados como as práticas e usos reiterados com conteúdo lícito e relevância jurídica.” (Tartuce, 2019)**
- **Costumes segundo a lei**
- **Costumes na falta da lei**
- **Costumes contra a lei**
- **Princípios Gerais do Direito: Por sua abstração, possuem muito conceitos. Mas, basicamente, são regras gerais que orientam todo o ordenamento jurídico. Para Tartuce, diferem das normas, por serem mais amplos e abstratos, além de que muitas vezes possuem posição definida na Constituição Federal.**

PRINCÍPIOS DO CÓDIGO CIVIL DE 2002

Os três paradigmas a serem perseguidos:

- **SOCIALIDADE – Função (fim) social.**

  Função social do contrato (art. 421) e função social da propriedade (art. 1.228).

  Alcançar o bem comum.

- **ETICIDADE – Solução mais justa e equitativa.**

  A boa-fé objetiva (CC, art. 422) e o abuso de direito (CC, art. 187)

- **OPERABILIDADE (ou concretude) – Maior praticidade na execução do direito.**

  Livrar-se de abstrações.

  Inserção do termo pessoa no art. 1º do Código Civil: "toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil"

  Distinção entre prescrição e decadência, tornando mais fácil operar tais institutos.

PROCESSO DE CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO CIVIL

Impacto anterior

Impacto atual

O CÓDIGO CIVIL DE 2002

- **Análise comparativa:**
  - **O Código Civil de 1916 – preocupação com a propriedade, proteção patrimonial.**
  - **O Código Civil de 2002 – proteção da pessoa humana no âmbito das relações privadas.**

O CÓDIGO CIVIL DE 2002

- “Cuida-se de normas que não prescrevem uma certa conduta, mas, simplesmente, definem valores e parâmetros hermenêuticos. Servem assim como ponto de referência interpretativo e oferecem ao intérprete os critérios axiológicos e os limites para aplicação das demais disposições normativas“ (Gustavo Tepedino)
- As cláusulas gerais e os conceitos jurídicos indeterminados:
- Segundo Pietro Perlingieri: “legislar por cláusulas gerais significa deixar ao juiz, ao intérprete, uma maior possibilidade de adaptar a norma às situações de fato”.
- A função social do contrato (art. 421).
- A boa-fé objetiva (art. 422).

CIVILIZAÇÃO DO DIREITO CONSTITUCIONAL

- A Constituição Federal de 1988 conferiu maior eficácia aos institutos fundamentais do Direito Civil, à luz de valores fundamentais aclamados como garantias e direitos fundamentais do cidadão.
- Migração de princípios fundamentais do Direito Privado para a sede constitucional.

EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

- **Reconhecimento da aplicação dos direitos fundamentais nas relações estritamente privadas.**
  - **De acordo com Dirley da Cunha Júnior, “o fenômeno de constitucionalização do Direito Civil tem gerado, como importante consequência, a aplicabilidade dos direitos fundamentais às relações privadas”.**
- **Em toda e qualquer relação jurídica entre particulares, devem estar salvaguardados os direitos fundamentais dos sujeitos.**

EFICÁCIA HORIZONTAL, VERTICAL E DIAGONAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

Eficácia Horizontal

Particular — Particular

Eficácia Vertical

Estado X Particular

Eficácia Diagonal

Particular hipossuficiente

Direitos Humanos Fundamentais

EFICÁCIA SUPRALEGAL DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS

- **(Ou) Aplicação dos tratados e convenções internacionais no âmbito das relações de Direito Civil; Convencionalização do Direito Civil.**
- **Emenda Constitucional nº 45.**
- **Os tratados e convenções internacionais que versem sobre direitos humanos e forem aprovados por três quintos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, por meio de decreto legislativo, terão status correlato a uma emenda constitucional.**
- **Ex.: Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência assinada em Nova Iorque e aprovada pelo Decreto Legislativo nº 186/08, incorporada ao ordenamento brasileiro com status de norma constitucional.**

EFICÁCIA SUPRALEGAL DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS

Qual seria o status normativo dos tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos anteriores à Emenda Constitucional nº45, bem como dos tratados e convenções sobre direitos humanos posteriores à aludida emenda não aprovados com as formalidades indicadas?

- **Possuem eficácia supralegal – situados em uma posição imaginária, entre a altitude constitucional e as leis infraconstitucionais (ordinárias e complementares).**

Ou seja, temos duas situações:

- **Quando congregar o aspecto material, versando sobre direitos humanos, e o aspecto formal, aprovado de acordo com o procedimento constitucional = terá status de emenda constitucional.**
- **Quando trouxer consigo apenas o aspecto material, versar sobre direitos humanos, terá eficácia supralegal, pairando acima da legislação infraconstitucional, mas em nível inferior à norma constitucional.**
- **Controle de constitucionalidade e controle de convencionalidade.**

EFICÁCIA SUPRALEGAL DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS

Não dispondo sobre direitos humanos, os tratados e convenções internacionais serão incorporados em sede infraconstitucional comum, ao lado da legislação ordinária = Será uma norma como outra qualquer.

A EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS SOCIAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS

- **Os direitos sociais dizem respeito a categorias jurídicas voltadas à implementação da igualdade jurídica, credenciando o seu titular a exigir posturas proativas do Estado para efetivar os seus direitos fundamentais, em situações sociais desiguais.**
- **Conferem um tratamento de preferências e de desigualdades para pessoas cuja situação social reclame a diferenciação jurídica.**
- **Ex.: Proibição de cláusula limitadora do tempo de internação hospitalar, por afrontar os direitos sociais.**
  - **Súmula 302, STJ.**

TESE DO ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL

- Uma generalizada desordem jurídica, social e política em relação a determinados direitos sociais que não consegue ser resolvida pelo Poder Judiciário sem a participação direta dos demais poderes e da sociedade privada.
- Constatação de uma prática generalizada, difusa, de afrontas aos direitos fundamentais e sociais.
- Não prevista expressamente no Texto Constitucional.
- Reclama um maior ativismo judicial.
- Remédios para o problema estrutural detectado.
- Ex.: Profunda crise do sistema prisional brasileiro.

ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL - ECI

Justiça determina que Estado não contingencie recursos para segurança pública

Publicação: 2018-10-10 17:20:00 | Comentários: 0

O Juízo da 3ª vara da Fazenda Pública de Natal atendeu o pedido do Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) e determinou que não haja contingenciamento de verbas previstas para segurança pública em 2019. Na ação civil, a 70ª Promotoria de Justiça defende a ocorrência de um estado de coisas inconstitucional na segurança pública do Rio Grande do Norte.

https://tribunadonorte.com.br/noticia/justia-a-determina-que-estado-na-o-contingencie-recursos-para-segurana-a-paoblica/426895

BIPARTIÇÃO DAS NORMAS JURÍDICAS: REGRAS E PRINCÍPIOS

- **OS PRINCÍPIOS – são normas que determinam que algo seja realizado na maior medida possível, dentro do contexto jurídico e real existentes.**
  - **As bases sobre as quais se constrói o sistema jurídico.**
  - **Enunciados com força normativa que tendem à produção de efeitos concretos, que emergem do garantismo constitucional, voltados, em especial, à valorização da pessoa humana e à afirmação de sua dignidade.**
  - **Casuístico.**
- **AS REGRAS – são relatos descritivos de condutas, com um conteúdo objetivo, certo e específico, a partir dos quais, mediante uma atividade de verdadeira subsunção, haverá o enquadramento de um fato cotidiano à previsão abstrata na norma atingindo-se um objetivo.**
  - **São mandados de definição – e não de otimização, qual os princípios.**
  - **“Tudo ou nada”.**
  - **Apriorístico.**
- **Não existe hierarquia entre princípios e regras.**

TÉCNICA DE PONDERAÇÃO DE INTERESSES (BALANCEAMENTO)

- **Conflitos entre diferentes princípios – os clássicos métodos hermenêuticos (critério da especialidade, anterioridade e da hierarquia) se mostram insuficientes e pouco eficientes para dirimir colisões principiológicas, em razão do elevado grau de abstração, generalidade e indeterminação de cada um dos princípios em conflito.**
- **Deve-se se sopesar as normas-princípios buscando descobrir qual dos valores colidentes respeita, com maior amplitude, a dignidade da pessoa humana.**
- **Devem ser justapostas em uma balança imaginária as normas em conflito.**

- **Ex.: Admissibilidade de prova ilícita em uma ação de suspensão ou de destituição do poder familiar, protegendo a criança ou o adolescente (CF, art. 227)**

TÉCNICA DE PONDERAÇÃO DE INTERESSES - VAQUEJADA

- **Por meio da técnica de ponderação de interesses, o STJ terminou por reputar incompatível com a Constituição da República uma lei estadual do Ceará que regulamentava a prática de vaquejadas.**

A obrigação de o Estado garantir a todos o pleno exercício de direitos culturais, incentivando a valorização e a difusão das manifestações, não prescinde da observância do disposto no inciso VII do art. 225 da Carta Federal, no que veda a pratica que acabe por submeter animais à crueldade. Discrepa da norma constitucional a denominada vaquejada." (STF, Ac. Tribunal Pleno, ADIn 4983/ CE, rel. Marco Aurélio, j. 6.10.16)

"Vaquejada – Manifestação cultural – Animais – Crueldade manifesta – Preservação da fauna e da flora – Inconstitucionalidade.

DERROTABILIDADE (SUPERABILIDADE OU DEFESEABILITY) NOS CASOS EXTREMOS (EXTREME CASES)

- **Para esses casos, não existe uma resposta correta, e eles não podem ser decididos senão ferindo o ordenamento jurídico.**
- **De acordo com Luís Roberto Barroso, "há hipóteses em que a adoção do comportamento descrito pela regra violará gravemente o próprio fim que ela busca alcançar".**

A técnica de ponderação de interesses não serve aqui, pois a colisão é entre normas-regras – modelo do "tudo ou nada".

- **A excepcionalidade da situação ativa um fator de fundo que impede a decorrência natural, que seria a previsão contida na regra.**
- **Ou seja, supera-se, em concreto apenas, a norma regulatória, afastando-a episodicamente, permitindo uma decisão judicial baseada na coerência, homenageando os valores humanistas da Constituição da República.**

DERROTABILIDADE (SUPERABILIDADE OU DEFESEABILITY) NOS CASOS EXTREMOS (EXTREME CASES)

“É pelo direito a casar-se que os espanhóis Daniel e Rosa Moya Peña lutam agora. A residir na Coruña, estes irmãos, que há 35 anos iniciaram uma relação marital, conseguiram em 2010 que o Estado espanhol os reconhecesse a ambos como progenitores dos filhos que entretanto já são adultos. Foram décadas a lutar nos tribunais.

‘Se morrer, já podem herdar de mim. Legalmente são meus filhos e não sobrinhos', congratulou-se Daniel em declarações ao jornal espanhol El País.

A história do amor destes irmãos já foi levada aos ecrãs espanhóis no filme Más que Hermanos. Sinopse: Dani cresce com a irmã e a mãe, cuja traumática separação leva à institucionalização de alguns dos sete filhos. Rosa cresce num orfanato. Em 1977, divertia-se com as amigas numa discoteca de Madrid quando um desconhecido a convida para dançar. Recusa. Duas semanas depois,O acaso volta a juntá-los. Apaixonam-se. Seis meses depois reparam na coincidência dos apelidos. Confrontados os registos de nascimento verificaram que os pais eram os mesmos. Separaram-se. Na altura, o incesto ainda era crime. Cinco meses depois, concluíram que não conseguiam manter-se afastados. Assumiram a conjugalidade. As resistências que tiveram de furar não são alimentadas apenas por questões morais" (Disponivel em: <http://www.publico.pt/sociedade/noticia/lei-portuguesa-nao-penaliza-amor-entre-irmaos-1547025>).

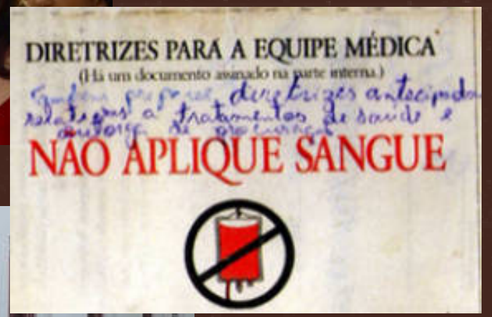
DURA LEX SED LEX = "A LEI É DURA, MAS É A LEI"? PUNIR POR INCESTO MESMO ASSIM?

DESACORDOS MORAIS RAZOÁVEIS

- Hard cases (casos difíceis) – aqueles não cobertos por uma regra especifica e clara, a determinar sua solução, ou seja, sem deixar claro como devem ser decididos.
  - Comumente apresentam alto grau de moralidade subjacente, evolvendo aspectos muito pessoais, de conteúdo religioso, sexual, filosófico etc.
- Desacordos morais razoáveis – matérias polêmicas, complexas, sobre questões emergentes ou persistentes, para as quais existe a possibilidade de admitir soluções antagônicas. São posições divergentes inteiramente porém constitucionalmente (juridicamente) legítimas, coexistindo no seio da sociedade.

DESACORDOS MORAIS RAZOÁVEIS

- Eutanásia e suicídio assistido x Direito à morte digna;
- Recusa de transfusão de sangue por pessoas adeptas da religião Testemunhas de Jeová;
- Descriminalização das drogas leves;
- Aborto – pro choice x pro life.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

TARTUCE, Flávio. Direito Civil: Lei de introdução e parte geral. 16. ed. Brasil: GEN – Forense, 2020.

FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: Parte Geral e LINDB. 18 ed. amp. e atual. Salvador: Juspodivm. 2020. 1. v.

FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson; NETTO, Felipe Braga. Manual de Direito Civil. 5 ed. amp. e atual. Salvador: Juspodivm. 2020.

KAHOOT

https://create.kahoot.it/share/direito-civil-1/461fe31c-f964-4280-8ab1-93febd4017d7

OBRIGADA!